粉笔直播课

理论讲练-刑法 2

（笔记）

主讲教师：陆川

授课时间：2026.01.18

粉笔事考·官方微信

理论讲练-刑法 2（笔记）

【答案汇总】

四、故意犯罪形态 1-4：BCA √

五、共同犯罪 1-5：B/CD/B/D/×

第三节刑罚 1-5：B/ABD/C/B/D；6-10： √ √ × ×D

第四节刑罚的具体运用 1-2：DD；4-5：D/AB；6-7：DB

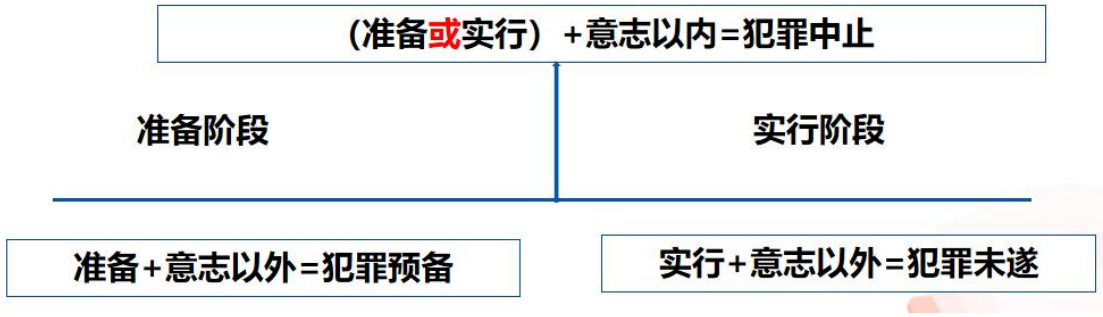
【注意】本节课讲解课后题不会留太多时间做题，同学们要提前预习，做课后题。没有听明白或过快、过慢可以及时提出，进行调整。本节课预计讲到缓刑。

四、故意犯罪形态

一、犯罪预备

二、犯罪未遂

三、犯罪中止



【解析】

1. 故意犯罪的形态：宏观上包括完成形态和未完成形态。

（1）完成形态：一般犯罪而言，达到犯罪目标即完成形态。如甲要杀张三，

目标是将其杀死，甲一刀捅下去，张三死了，此时杀人的行为、目标已经完成，即故意杀人的完成形态，也叫故意杀人的既遂。

（2）未完成形态（重点）：

①未完成形态包括预备、未遂、中止三种。

②如甲要杀张三，只要张三最终没有死，甲的犯罪没有达成，就是未完成形态。

2. 整个犯罪过程分为两个阶段，即准备阶段和实行阶段。

（1）准备阶段：为了杀人买刀、买枪、买毒药的行为，属于准备阶段。在准备阶段由于意志以外的原因被迫停下来，此时是犯罪预备。如甲买了刀想杀张三，刀放在家中，结果刀找不到了，没办法杀张三了。买刀是准备阶段，刀找不到了是由于意志以外的原因，被迫停下来，此时是犯罪预备。

（2）实行阶段：甲拿着刀，真刀真枪砍向人，即实行阶段。如果在实行阶段，由于意志以外的原因被迫停下来，此时是犯罪未遂。如甲买了一把刀要杀张三，正要落刀时，张三比较厉害，一脚把刀踹飞，甲无法杀张三，正要落刀是实行阶段，由于张三比较厉害把刀踹飞，是甲意志以外的原因被迫停了下来，属于犯罪未遂。

（3）犯罪中止：整个犯罪过程中，无论是准备阶段还是实行阶段，只要由于意志以内的原因，主动停了下来，都是犯罪中止。如甲拿刀要杀张三，走在路上时甲感觉张三很可怜，于是不想杀他，离开了，此时属于犯罪中止。

3. 注意：预备形态、未遂形态和中止形态，无论哪一种阶段都属于故意犯罪的未完成形态，都需要承担刑责，只是量刑不同。

（一）犯罪预备

犯罪预备，是指为了犯罪，准备工具，制造条件，但由于行为人意志以外的原因而未能着手实行犯罪的情形。

常见的准备工具、制造条件：踩点、蹲点、买凶器、尾随跟踪、出发在路上。

对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻或者免除处罚。

【解析】犯罪预备：准备阶段，由于意志以外的原因被迫停下。为了犯罪，准备工具，制造条件。

1.常见的准备工具、制造条件：

（1）踩点：如为了偷东西先去勘测地形。

（2）蹲点：如守在某地等待被害人出现。

（3）买凶器：如为了杀人而买刀、买枪、买毒药的行为。

（4）尾随跟踪：如为了杀张三一直尾随跟踪他到没人的地方。

（5）苦练技术：如为了杀人，练葵花点穴手、排山倒海等。

（6）出发在路上：如前往被害人家中、向被害人家中走去，是常见的准备阶段。如果出发在路上由于意志以外的原因被迫停下来，是犯罪预备，属于准备阶段。如果由于意志以内的原因主动停下来，是犯罪中止。因此出发在路上一般不成立犯罪未遂。

2.总结：准备阶段是由于意志以外的原因被迫停下来。如张三去李四家中偷东西，在去他家的路上被甲走漏风声，在路上被警察抓住了，“出发在路上”是准备阶段，“被甲走漏风声”属于意志以外的原因，张三属于犯罪预备。

3.量刑：对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻或者免除处罚。“可以”是有选择的意思，比照既遂犯“从轻、减轻或者免除处罚”（三个词都全了）。

（二）犯罪未遂（欲而不能）

犯罪未遂是指已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的情形。

对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

【解析】犯罪未遂（欲而不能）：在实行阶段，由于意志以外的原因，被迫停了下来。某人想要，但是客观上办不到。

1.犯罪未遂说明已经着手实行犯罪（开始干）：如买毒药属于准备阶段，如果趁着那个人洗手的时候把毒药放进杯子里，即实行阶段。

2.由于意志以外的原因，被迫停了下来，即犯罪未遂。

（1）被第三人发现：如甲到张三家偷东西，正在偷时，结果保安来了，甲就逃跑了，属于意志以外的情形。

（2）自己能力不足：如杀人时砍不过对方被反杀。

3.对于未遂犯，可以（有选择）比照既遂犯从轻或者减轻处罚。注意：对比

记忆。预备犯可以比照既遂犯从减免，多了一个免除，而未遂犯没有免除处罚。预备犯是在准备阶段，没有做实际的事，可以免除处罚，但是未遂犯已经真刀真枪开始干了，不能免除处罚。

（三）犯罪中止

犯罪中止，是指犯罪分子在实施犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的行为。

对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。

【解析】

1. 犯罪中止：无论是准备阶段还是实行阶段，只要由于意志以内的原因主动停了下来，即犯罪中止。

（1）在实施犯罪的过程中（未完成的时候），由于意志以内的原因停下来。注意：若犯罪完成，则不成立中止，而是犯罪既遂。常见的是事后返还赃物的情形，如甲到张三家，将张三的祖传宝物偷回家，结果第二天发现宝物不值钱又送回去，此时不能成立犯罪中止，已经偷到手了，一旦犯罪完成，构成犯罪既遂。再如拐卖妇女儿童罪，只要儿童被甲弄到手即既遂，即便没卖出去再送回去也是既遂。再如挪用公款罪，只要挪出来就构成既遂，哪怕最后再还回去也是既遂。

（2）自动放弃犯罪，即意志以内主动停下来（主观上不想干了）。如甲要杀张三，结果想到将张三杀死，自己也要承担刑事责任，刑法中规定杀人要偿命，于是主动放弃杀张三，属于意志以内主动停下来。

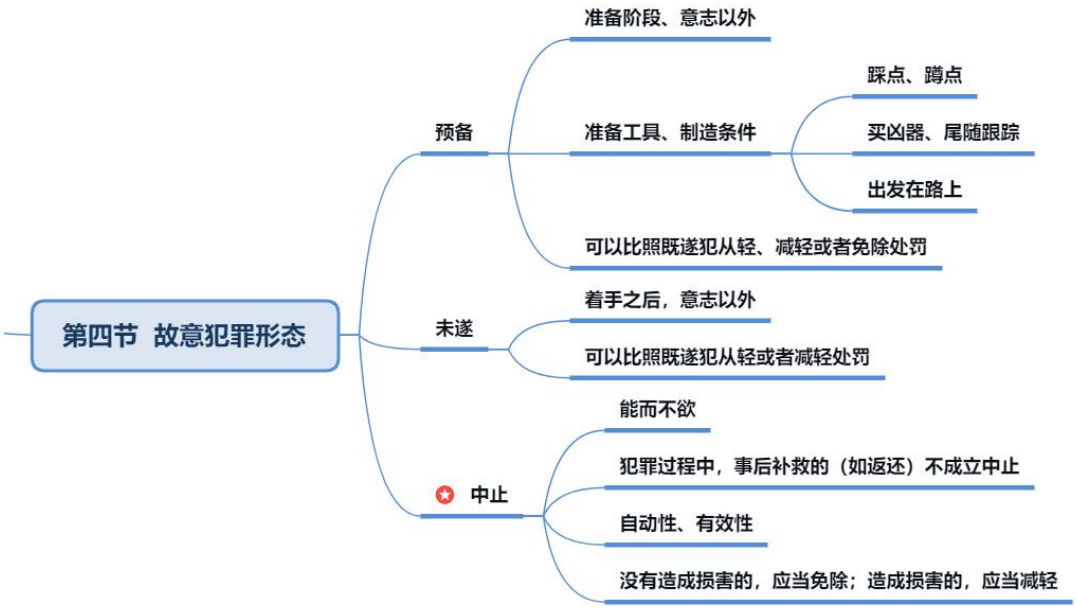
（3）自动有效地防止犯罪结果发生：

①有效性：成立犯罪中止一定要成功防止犯罪结果发生，具备有效性，才能成立犯罪中止。

②如甲要杀张三，捅了几刀后，张三没有死，甲的犯罪没有完成，甲想把张三送往医院救活。若医生将其救活了，此时甲的行为具备有效性，成立犯罪中止。如果张三没有被医生救活，张三死亡了，说明甲的行为不具备有效性，成立犯罪既遂。

2. 量刑：对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。注意：预备犯和未遂犯是“可以”，中止犯是“应当”（必须、一定）

免除处罚，因此中止犯的量刑比较轻一些，法律会鼓励犯罪分子主动“放下屠刀，立地成佛”。



【注意】故意犯罪形态：两种考法。

1. 给出案例，问属于既遂、预备、未遂还是中止：既遂看是否完成犯罪目标（如想杀张三，张三死了即完成目标，未死则未完成目标）；预备是准备+意志以外的原因；未遂是实行阶段+意志以外的原因，即欲而不能；中止无论是准备还是实行阶段，只要是意志以内的原因，都叫犯罪中止，又称能而不欲（能做，但是主观上不想）。

2. 考查量刑：对比记忆。

（1）预备犯和未遂犯都是可以比照既遂犯从轻、减轻处罚，只不过预备犯多了免除处罚，而未遂犯没有免除处罚。

（2）中止犯：没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。

3. 细节：

（1）出发在路上：常见的准备阶段，不属于实行阶段。

（2）事后补救不成立中止：事后返还赃物依然是既遂。

（3）中止犯要具备有效性。

1.（2023 四川泸州·单选）金某私自印制了 2000 多份宣传资料，在甲市多处张贴、散发，以“捐功德积福”为由，欺骗市民向其个人账户转款。截至案发，未有钱转入金某个人账户。金某的行为可判定为（B）。

A. 犯罪中止 ✗　　B. 犯罪未遂

C. 犯罪预备　　D. 犯罪既遂

【解析】1. 已经开始实行，目的是骗到钱，但是最终未骗到钱，原因是大家的反诈意识强，其能力不足，因意志以外的原因被迫停下来，属于犯罪未遂。【选 B】

2.（2020 四川德阳·单选）某日凌晨，醉酒的李某在回家路上遇见一背包女青年，想到自己最近刚丢了工作，手头紧，便产生了抢劫的想法。于是，李某尾随女青年行至一僻静小路，见四下无人，灯光黑暗，遂上前实施抢劫。哪知女青年是擒拿格斗的好手，李某几次三番都未能得手，反被女青年打得落花流水，最后狼狈而逃。下列对本案的分析正确的是（C）。

A. 李某是在醉酒情况下实施的抢劫行为，因而不构成犯罪

B. 李某的行为属于犯罪中止

C. 李某的行为属于犯罪未遂

D. 女青年的行为属于紧急避险

【解析】2. C 项：实行阶段，因意志以外的原因（自己能力不足）被迫逃跑，属于犯罪未遂，当选。A 项：醉酒应当一样，排除。D 项：属于正当防卫，排除。【选 C】

3.（2019 四川眉山·单选）老陈为抢劫而购买了匕首等犯罪工具后，因发生车祸而未实施犯罪，其行为属于（A）。

A. 犯罪预备　　~~B. 犯罪中止~~

C. 犯罪未遂　　~~D. 犯罪既遂~~

【解析】3. A 项：准备阶段（买凶器）+意志以外的原因（发生车祸），当选。【选 A】

4.（2022 四川成都·判断）某日，李某偷走王某价值 3 万元的电动车，准备转手出售。三天后，李某发现该车不易出售，又担心被发现，便主动将电动车归还王某。根据刑法，李某的行为构成盗窃罪既遂。（√）

【解析】4. 事后返还赃物依然构成既遂。【选 √】

五、共同犯罪

（一）共同犯罪的概念

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

（二）共同犯罪的成立条件

成立条件：

1. 必须二人以上。（主体）

2. 必须有共同故意。（主观方面）

3. 必须有共同行为。（客观方面）

【解析】共同犯罪：

1. 概念：二人以上共同故意犯罪。至少两个人都犯了罪才能成立共同犯罪。

2. 共同犯罪的成立条件：同时满足三个条件（是且的关系）。

（1）主体人数要求：必须二人以上。

①刑法中的“以上、以上”包含本数。

②人数上的要求：X≥2 人。

（2）主观方面的要求：必须有共同故意。

①这些人朝着同一个目标共同犯罪。

②若一个人是故意，另一个人是过失导致的，此时不构成共同犯罪。如张三想越狱，趁着狱警李四睡着时越狱，张三和李四不成立共同犯罪，因为一个人是故意的，另一个人是过失的。二人都是过失导致也不成立共同犯罪。

（3）客观方面的要求：必须有共同行为。

①共同行为并不是要共同做一模一样的事，而是指这些人朝着同一个目标，要么有意思联络（可以理解为共谋），要么有共同协作（可以理解为共同实行），二者有之一就算有共同行为。

②如张三和李四共谋去盗窃，盗窃当天张三有事没去，只有李四一个人去了。

满足 2 人以上（张三、李四），有共同故意（都想盗窃），有共同行为（共谋或者共同实行，二者有之一就算），即便张三没有去成，仍成立共同犯罪。共谋是提供思路的情形，也很重要。

排除情形：

1. 同时犯。

2. 超出共同故意之外的犯罪。

3. 利用他人不知情。

【解析】排除情形：考试时会给出一些情形，相当于好多人一起去干坏事，但以下情形不叫做共同犯罪，而是共同犯罪的排除情形。

1. 同时犯：偶然遇到的情形。比如甲去张三家偷东西，刚进屋发现对面乙也在张三家偷东西，于是甲和乙相视一笑，各偷各的、各回各家、各找各妈。甲和乙不成立共同犯罪，虽然二者都在盗窃，但是没有事前同谋、没有共同故意，所以是同时犯。如果两人都被抓到，各自定各自的盗窃罪，不是共同盗窃。

2. 超出共同故意之外的犯罪：

（1）如张三和李四约好一起去盗窃，在盗窃当天，李四偷完东西就走了，张三不仅偷了东西，还杀了人。两人只有对盗窃行为的共同故意，杀人行为是超出共同盗窃之外的犯罪，谁杀人谁担责，张三自己杀了人，张三自己担责，与李四无关。

（2）可以说张三和李四两个人共同盗窃，但是不能说两个人共同杀人（对李四不公平），所以杀人行为是超出共同故意之外的犯罪。

3. 利用他人不知情：背后的黑手叫间接正犯，间接去干的那个人把别人当作工具人来利用。

（1）比如某医生想要毒死一位病人，但是不想自己干，于是把有毒的针交给了一名不知情的护士，护士将针打给了病人，病人死亡，即医生利用护士不知情去干坏事的情形，医生是间接正犯，护士是工具人，只有医生担刑责，因为护士压根不知情，不能说护士和医生是共同犯罪。

（2）再如一个人要运偷来的东西，骗别人说是自己的、让别人帮忙运，属于利用别人的不知情。

（三）共犯人的分类及其刑事责任

【解析】共犯人的分类及其刑事责任：共同犯罪中有很多人一起犯罪，每个人的分工和起到的作用都是不一样的，因此根据分工和作用将共同犯罪人分为四大类，分别是主犯、从犯、胁从犯、教唆犯。

1. 主犯及其处罚

组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

（1）主犯

①犯罪集团中的首要分子。

②其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。

（2）处罚

对于组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

【解析】主犯及其处罚：

1. 主犯：包括两种情况。

（1）犯罪集团中的首要分子：

①犯罪集团：典型如黑帮团伙。如电视剧《狂飙》中高启强的强盛集团就是犯罪集团。关于犯罪集团有很多要求，如要有一定的组织架构、要有一定的资金实力、要称霸一方、要对当地有一定的影响等。

②犯罪集团有人数上的要求：至少是 3 个人的犯罪团伙（X≥3 人）。

（2）其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子：如张三和李四偷东西，张三进去偷，李四在外面把风，此时张三是主犯。

（3）判断：主犯至少在 3 人当中才能够成立主犯（错误），原因：2 个人也能成立主犯。

2. 处罚：

（1）正常的共同犯罪，主犯按正常处罚即可。

（2）对于组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。注意两个关键词“集团所犯的”“全部罪行处罚”。

①全部罪行处罚：比如强盛集团一共干了 6 件坏事，其中 3 件事是强哥亲自参与的，另外 3 件事强哥没有参与，强哥作为犯罪首要分子，需要对 6 件事承担刑责。因为强哥平时呼风唤雨，见真章的时候也要担起责任、不能跑。

②比如集团中的小弟（如小龙、小虎），他们为了满足自己的私欲，喜欢拉一些私活，这些私活和集团的利益没有关系，所以老大不需要对其拉的这些私活担责。如果与集团的利益无关，则老大不需要担责。

2. 从犯及其处罚

从犯是指在共同犯罪中起次要或者辅助作用的犯罪分子。

对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。

思考：在两个人的共同犯罪中

1. 有没有可能两者都是主犯？

2. 有没有可能一个主犯一个从犯？

3. 有没有可能两个都是从犯？

【解析】从犯及其处罚：

1. 从犯：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的犯罪分子。如张三、李四一起偷东西，张三进去偷，李四在外面把风，李四是起到次要辅助作用的犯罪分子，叫做从犯。

2. 量刑：对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。

（1）记忆“唯一”。在刑罚中，应从、减、免，只有从犯是这样搭配的，具有唯一性，其他的任何都没有这样的搭配。做题时出现任何其他的，只要与“应从、减、免”搭配的不是从犯，都是错误的。

（2）判断：

①未成年人犯罪应从、减、免（错误），原因：未成年人犯罪是应从、减，没有免除处罚。只有从犯搭配“应从、减、免”。

②对于从犯，可以从、减、免（错误），原因：“应当”是必须、一定的意思，“可以”是有选择的意思。

③对于从犯，应当比照主犯从轻、减轻或者免除处罚（错误），原因：“比照主犯”是 1979 年老刑法中的说法，现在已经没有这四个字了。

3. 思考：在两个人的共同犯罪中。

（1）有没有可能两者都是主犯：有可能。比如两个人偷东西，两个人都进去偷，都起到主要作用，此时两人都是主犯。

（2）有没有可能一个主犯一个从犯：有可能。比如一个人进去偷，一个人在外面把风。

（3）有没有可能两个都是从犯：不可能。从犯是相对主犯而言的，二人共同犯罪中只有从犯、没有主犯的现象是不存在的，至少要有一个主犯。

3. 胁从犯及其处罚

胁从犯是指被胁迫参加犯罪的人，即在他人威胁下不完全自愿地参加共同犯罪，并且在共同犯罪中起较小作用的人。

对于胁从犯，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。

【解析】胁从犯及其处罚：

1. 胁从犯：被胁迫参加犯罪的人，即在他人的威胁下不完全自愿地参加共同犯罪，并且在共同犯罪中起较小作用的人。同时满足两个条件才能叫胁从犯。

（1）比如李四让张三和自己一起去盗窃，张三不去，李四打了张三几个巴掌，张三还是不去又被李四打了几个巴掌，最终张三在李四的威胁下终于和李四一起去盗窃，在偷的过程中一点也不积极，偷得也不多，起到较小的作用，此时张三是胁从犯。

（2）如果张三在李四的威胁下，不完全自愿地去参加共同犯罪，但是在偷的过程中发现偷东西这件事很有意思，可以满足私欲、偷到东西，还很刺激，看到什么都拿，起到主要作用，此时张三不是胁从犯，而是主犯。

2. 量刑：对于胁从犯，应当（必须）按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。

（1）从轻、减轻、免除，从前往后优惠力度依次递增，优惠力度最大的是免除处罚，其次是减轻处罚，优惠力度最小的是从轻处罚。

（2）胁从犯的优惠力度都比较大，量刑比较轻，也是合理的，因为胁从犯

主观上不完全自愿，客观上起到较小的作用，社会危害程度较小，所以量刑比较轻。

3. 如果一个人完全被强制，则不成立胁从犯。比如甲要杀张三，于是将小明打晕了，在小明手上握着一把刀将张三杀死，此时小明不是胁从犯，不承担刑责，什么的不知道。

4. 教唆犯及其处罚

教唆犯是指以劝说、利诱、授意、怂恿、收买、威胁等方法，将自己的犯罪意图灌输给本来没有犯罪意图的人，致使其按教唆人的犯罪意图实施犯罪，教唆人即构成教唆犯。

（1）教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。

（2）教唆不满 18 周岁的人犯罪的，应当从重处罚。

（3）如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以从轻或者减轻处罚。

【解析】教唆犯及其处罚：

1. 教唆犯指教唆别人，让不想犯罪的人犯罪了，教唆别人的人就叫做教唆犯。比较典型的是买凶杀人，比如甲想杀张三，把钱给李四，让李四帮自己杀张三，甲是教唆犯，李四是被教唆的人。

2. 教唆犯的三个考点：都是针对教唆犯（甲）而言的，不管李四做了什么事。

（1）教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。

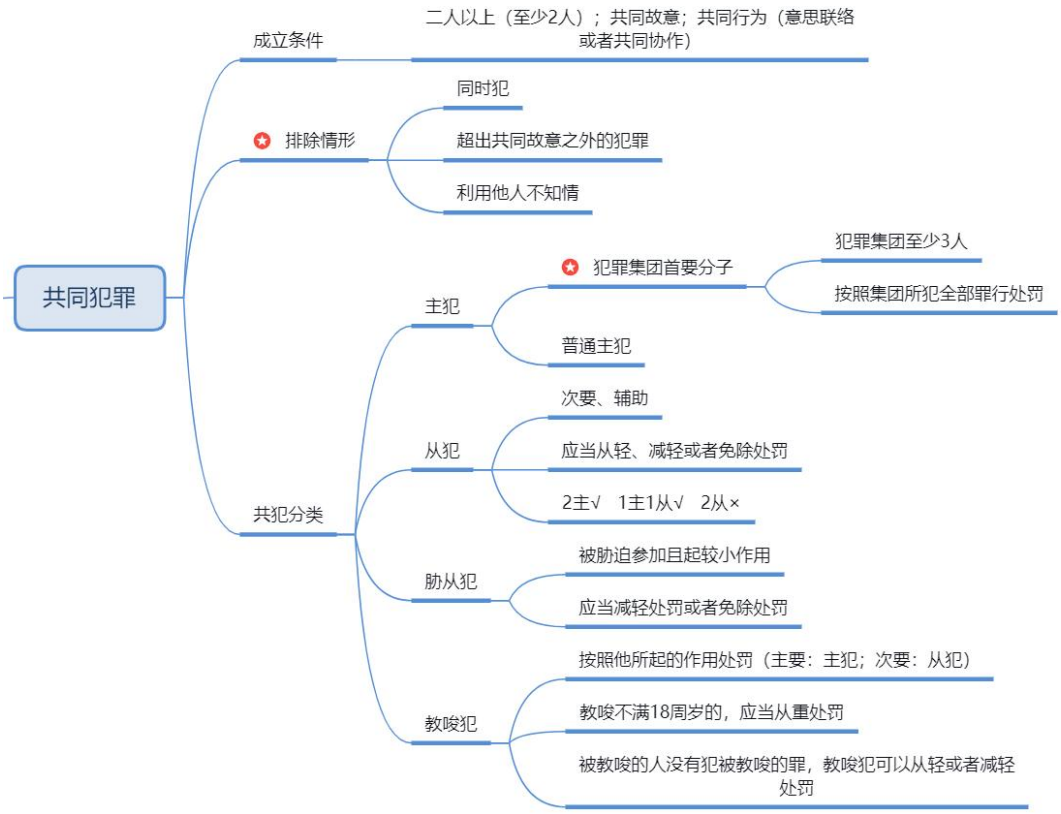
①一般情况下，教唆犯起到主要作用，按照主犯处罚。如买凶杀人，买凶的人一般起主要作用。但是教唆犯也可能起到次要或者辅助作用，此时按照从犯进行处罚。

②真实案例：夫妻二人吵架，丈夫一气之下把事情和朋友说了，让朋友去他家杀了他妻子，他的朋友真的到其家中杀了他的妻子，整个过程非常凶残，将其妻子大卸八块，最后法官认定，在这起共同犯罪中，朋友更残忍，对案件过程和结果都起到了主要作用，对其按照主犯处罚；丈夫起到次要辅助作用，因此按照从犯进行处罚。所以教唆犯既有可能起到主要作用，也有可能起到次要、辅助作用。判断：教唆犯一定起到主要作用（错误），原因：也有可能起到次要、辅助

作用。

（2）教唆不满 18 周岁的人犯罪的，比如把孩子教坏，应当从重处罚。

（3）如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯是教唆未遂，可以从轻或者减轻处罚（宽大处理）。比如甲让张三杀人，结果张三没有杀人，教唆张三的甲是教唆未遂，此时可以从轻或者减轻处罚。



【注意】

1. 判断：至少 3 人以上才能成立共同犯罪（错误），原因：2 人以上就可以成立。

2. 判断：共同犯罪在主观方面必须要有共同故意（正确）。

3. 两人相约抢劫，其中一人杀人了，对于杀人行为不能叫做共同犯罪，杀人行为是超出共同故意之外的犯罪。

4. 判断：偷东西时偶然遇到同行，成立共同犯罪（错误），原因：应该是同时犯。

5. 判断：关于犯罪集团，至少 5 人的团伙才能称为犯罪集团（错误），原因：3 人以上，至少 3 人。

6.判断：对于从犯，可以从轻、减轻或者免除处罚（错误），原因：不是“可以”，是“应从减免”。

7.如果一个人被胁迫参加共同犯罪，起到较大的作用（属于主犯），不能按照协同犯进行处罚。

8.判断：教唆不满 18 周岁的人犯罪的，应当从重处罚（正确），原因：把孩子教坏了，应当从重处罚。

9.被教唆的人未听话，教唆未遂可以从轻、减轻处罚。

试题演练

1.（2021 四川内江·单选）医生张某在给病人开药时，因诊断错误开错药，护士郭某在用药时不小心用量过大致病人死亡，那么（　）。

A.张某和郭某构成共同犯罪

B.张某和郭某不构成共同犯罪

C.张某构成故意杀人罪，郭某构成过失杀人罪

D.属于意外事件

【解析】1.A、C 项：二人主观上都是过失，开错药不小心，排除。D 项：作为医生、护士应当预见，不是不能预见，排除。【选 B】

2.（2021 四川眉山·多选）甲、乙共谋去某商场行窃，为此二人曾一同去该商场踩点，并购置了行窃工具。之后，两人抵达该商场，甲留在商场外观望，乙撬门进入，乙在窃取了价值数万元的物品后，认为放火可以破坏现场。于是，乙在离开前用打火机点燃了商场内的纸张，待乙从商场出来后，甲、乙二人逃离现场。回去分赃时，乙把放火之事告诉了甲。根据我国刑法，下列说法正确的有（　）。

A.乙独自构成盗窃罪　　B.甲、乙构成共同放火罪

C.甲、乙构成共同盗窃罪　　D.乙独自构成放火罪

【解析】2.C 项：“甲、乙共谋去某商场行窃，为此二人曾一同去该商场踩点，并购置了行窃工具”，已经成立共同犯罪，当选。D 项：二人只对盗窃罪成立共同犯罪，放火罪是超出共同故意之外的犯罪，自己构成的自己担责，当选。

【选 CD】

3.（单选）关于共同犯罪，下列说法有误的是（　）。

A.共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪

B.对于从犯，可以从轻、减轻处罚或者免除处罚

C.如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以从轻或者减轻处罚

D.组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的是主犯

【解析】3.选非题。B 项：不是“可以”，是“应当”，当选。C 项：教唆未遂，排除。【选 B】

4.（单选）方某蓄意盗窃厂房附近堆放的焦煤，骗蒋某说自己买了一堆煤炭，向蒋某借拖拉机去帮助拉回，蒋某深信不疑，答应帮助。于是方某、蒋某共同装车，将焦煤拉回。蒋某的行为属于（　）。

A.从犯　　B.帮助犯

C.窝赃犯　　D.不构成犯罪

【解析】4.D 项：蒋某不知情，属于利用不知情的人干坏事，故蒋某不构成犯罪，当选。【选 D】

5.（判断）犯罪集团指五人以上为实施一种或几种犯罪而组织起来的共同犯罪组织，它是共同犯罪的特殊形式。（　）

【解析】5.犯罪集团是三人以上。【选×】

第三节　刑罚

【注意】我国刑罚包括两种，即主刑和附加刑。

1.主刑指对一个犯罪主要适用的刑罚，一个罪只适用一个主刑，主刑是独立的。

2.附加刑可以附加适用，也可以独立适用。

3.主刑有 5 种，附加刑有 4 种，所以我国刑罚共包括 9 种。

一、主刑

主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑 5 种。

【解析】

1. 主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑 5 种。5 种主刑从前往后严厉程度依次递增，我国最轻的主刑是管制，最重的主刑是死刑。

2. 考查选择题：常考死缓是不是主刑，死缓既不是主刑，也不是独立刑种，死缓只是死刑的一种适用方式而已。我国死刑包括死刑立即执行、死刑缓期执行。

1. 管制

管制，是指对犯罪分子不实行关押，但限制人身自由，依法实行社区矫正的刑罚方法。管制作为一种限制人身自由的刑罚，其期限为 3 个月以上 2 年以下，数罪并罚时最高不能超过 3 年。管制犯仅是自由受限，其他权利均受法律保护，故对于被判处管制的犯罪分子，在劳动中应当同工同酬，不得克扣、减少其应得收入。

判处管制，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在执行期间从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。

违反禁止令的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚。

【解析】

1. 管制：对犯罪分子不实行关押，意味着犯罪分子被判完之后可以回家待着，是我国最轻的主刑。

（1）毕竟被判了刑，需要由基层的司法工作人员（如司法局、司法所）对被判处管制的人实行社区矫正的刑罚方法。比如定期找他们沟通交流一下，纠正他们的犯罪恶习、犯罪心理，偶尔参加一些义务劳动。

（2）管制是回家待着，仍然可以参加劳动（可以上班），在劳动中应当同工同酬（干一样的活就要给一样的钱）。如甲被判处管制，乙是良好市民，只要甲和乙干一样的活就要给一样的钱，如搬砖都是一块 8 分钱，不能因为管制就差别对待，要同工同酬。

2. 刑期：管制的刑期是“3-2-3”。若因一个行为判处管制，期限为 3 个月以上 2 年以下，“以上、以下”包含本数。数罪并罚时（数个管制一起）最多不超过 3 年。

3. 判处管制，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在执行期间从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人，即禁止令。若某人因黑社会性质被判管制，则不让其去酒吧、KTV 接触黑道的人。违反禁止令的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚（不是撤销管制）。

2. 拘役

拘役，是剥夺犯罪人短期人身自由，就近在看守所实行劳动改造的刑罚方法。根据刑法的规定，拘役的期限为 1 个月以上 6 个月以下。数罪并罚时，最高不得超过 1 年。被判处拘役的犯罪分子，由公安机关在就近的看守所执行。在执行期间，被判处拘役的犯罪分子每月可以回家 1 天至 2 天；参加劳动的，可以酌量发给报酬。

【解析】

1. 拘役：相比于管制而言更严厉，管制不予关押，而拘役要被关起来，短期剥夺犯罪分子的人身自由，主要由公安机关就近关押在看守所进行执行。

（1）判处拘役，说明犯的罪不是很严重，执行期间每个月可以回家 1-2 天，相当于有“探亲假”，可以回家看看老婆孩子。

（2）虽然关在监狱内，但是可以参加劳动，比如缝皮球、踩缝纫机、做伞、做鞋垫等，参加劳动酌量发给报酬。酌量可以理解为看着给，看心情给，心情好则多给点，心情不好就少给点。

（3）区别：管制在外面干活，是同工同酬；拘役在里面干活，是酌量发给报酬。

2. 刑期：1-6-1，单独因为一个行为判处拘役，期限为 1 个月以上 6 个月以下；数罪并罚（数个拘役一起判）最多不得超过 1 年。

3. 对比记忆：拘役“1-6-1”和管制“3-2-3”放在一起记忆，二者是对称的。不要记混，管制在外面，所以时间可以长一点，是 3 打头的；拘役在里面，时间短一点，所以是 1 打头。

4.注意：拘役不等于拘留。

（1）常见的拘留叫行政拘留，还有刑事拘留（刑事强制措施）、司法拘留（法官对大闹法庭的人进行司法拘留）。行政拘留是行政处罚，而拘役是刑法中的刑罚。

（2）关的地方也不一样：

①公安机关下的派出所一般是处理案件的，如打 110 是当地辖区的民警出警处理案件，办身份证也是去辖区的派出所。派出所不关人，有个临时关押的地方，一般是几个小时。

②看守所关押的是刑事案件的相关人员，拘留所关押的是行政案件的相关人员。

③如李某峰涉嫌嫖娼，属于治安案件，而吴某凡涉嫌强奸罪、聚众淫乱罪，有网友 P 图二人在狱中见面、握手，实际二者不可能见面，因为案件不同，行政案件关押在拘留所，刑事案件关押在看守所，之后转移到监狱（长时间关押，如有期徒刑、无期徒刑等）中。

3.有期徒刑

有期徒刑，是剥夺犯罪分子一定期限的人身自由，实行强制劳动改造的刑罚方法。

有期徒刑的期限为 6 个月以上 15 年以下。数罪并罚时，有期徒刑总和刑期不满 35 年的，最高不超过 20 年；总和刑期在 35 年以上的，最高不能超过 25 年。

【解析】

1.有期徒刑：有期徒刑相对拘役时间会更长一些。

2.刑期：

（1）如果某人犯了一个罪，判有期徒刑有范围，是 6 个月以上 15 年以下（“以上、以下”都包含本数），在这个区间内酌情定最终刑期。

（2）如果犯了多个罪，此时不能无限往上加（比如加几千年、几百年，不切实际），涉及封顶问题（看刑期相加的总和 X）：

①总和 X＜35 年，数罪并罚后的刑期最多不超过 20 年。

②总和 X≥35 年，数罪并罚后的刑期最多不超过 25 年。

③比如张三犯了 3 个罪，每个罪都被判了 10 年，数罪并罚最高刑期是判 20 年（30 年＜35 年）；如果犯了 4 个罪，每个罪都被判了 10 年，数罪并罚最高判 25 年（40 年≥35 年）。

④在我国，有期徒刑最高是 25 年，不能再高了。西方国家则不同，可能判处几万年的刑期。

⑤如唐山吃烧烤打人事件，陈某被判 24 年有期徒刑，他是因为多个罪被判 24 年，因为一个罪最多 15 年，不可能到 24 年。涉及数罪并罚，有封顶，原判刑期大于 35 年，最终刑期才可能大于 20 年。

4. 无期徒刑

无期徒刑是剥夺犯罪分子终身自由，并强制劳动改造的刑罚方法。无期徒刑的刑期从判决宣判之日起计算，判决宣判前先行羁押的日期不能折抵刑期，无期徒刑减为有期徒刑后，执行有期徒刑，先行羁押的日期也不予折抵刑期。

先行羁押	审判	折抵

【解析】

1. 无期徒刑：理论上剥夺犯罪分子终身自由。实践中被判处无期徒刑的人若在里面表现比较好，会有减刑、假释等措施，可能关了十几年就出来了。

2. 折抵刑期：

（1）折抵刑期：比如张三犯罪，将其抓起来后不会立马审判，需要询问、调查、排期（我国司法资源有限，需要排档）等过程，在等待时往往把犯罪分子关起来，关的这段时间叫做先行羁押，排到之后进行审判，先行羁押的日期不能白羁押，要把先行羁押的日期扣掉，扣掉就叫做折抵刑期的过程。

（2）折抵刑期需要分情况，根据审判结果的不同而处理。

①如果最终的审判结果是管制（不关押），先行羁押将犯罪分子关起来了，最终审判结果不关押，折抵刑期时，关的 1 天折抵不关的 2 天。比如张三先行羁押 30 天，最终结果是要判 90 天的管制，再执行 30 天的管制即可（30 天的先行羁押折抵管制的 60 天，90 天-60 天=30 天）。

②如果被判处有期徒刑或拘役，有期徒刑和拘役都是关起来的，先行羁押也是关起来的，折抵刑期时是 1 比 1 折抵。比如甲先行羁押 30 天，最终审判结果是判 60 天的拘役，再执行 30 天的拘役即可（30 天的先行羁押折抵拘役的 30 天，60 天-30 天=30 天）。

③如果最终的审判结果是判无期徒刑，无期徒刑相当于无穷大，无穷大减去一个数还是无穷大，此时没必要折抵，故无期徒刑不折抵。

3. 记忆结论：管制 1:2 折抵，有期、拘役 1:1 折抵，无期徒刑不折抵。

5. 死刑

死刑是剥夺犯罪分子生命的刑罚方法。

适用条件：

（1）适用条件的限制。死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子。

（2）适用对象的限制。犯罪的时候不满 18 周岁的人和审判的时候怀孕的妇女，不适用死刑。审判的时候已满 75 周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外。

（3）死刑适用程序的限制。死刑除依法由最高人民法院判决的以外，都应当报请最高人民法院核准。死刑缓期执行的，可以由高级人民法院判决或者核准。

（4）死刑执行制度的限制。对于应当判处死刑的犯罪分子，如果不是必须立即执行的，可以判处死刑同时宣告缓期 2 年执行。

判处死刑缓期执行的，在死刑缓期执行期间，如果没有故意犯罪，2 年期满以后，减为无期徒刑；如果确有重大立功表现，2 年期满以后，减为 25 年有期徒刑；如果故意犯罪，情节恶劣的，报请最高人民法院核准后执行死刑；对于故意犯罪未执行死刑的，死刑缓期执行的期间重新计算，并报最高人民法院备案。

【解析】

1. 死刑：我国最严厉的主刑，剥夺犯罪分子生命的刑罚方法。既然这么严厉，有一些限制，不是所有人、所有情节都能判处死刑。

（1）适用条件的限制：死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子。考试不考查罪行极其严重有哪些，只是考查“极其严重”这几个字，目前我国还有 46 个罪名可能判处死刑，如抢劫、故意杀人、强奸、绑架等。

（2）适用对象的限制：犯罪的时候不满 18 周岁的人和审判的时候怀孕的妇女，不适用死刑。审判的时候已满 75 周岁的人，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外。

①犯罪的时候不满 18 周岁：如张三在 17 周岁杀人，在 19 周岁被审判，不适用死刑，因为他犯罪时不满 18 周岁。

②审判时怀孕的妇女，不适用死刑：此处的“审判时”是一种扩张解释，指妇女从关押（先行羁押的那一天开始计算）到执行（我国死刑一般采取枪决或者注射的方式，在执行的前一秒钟都算作执行之前）这段期间内，只要妇女怀过孕都不适用死刑，不用管孩子是否生下来，也不用管孩子是否流产。

a. 妇女在关押时怀孕，关押的第二天流产：不适用死刑，因为该妇女怀过孕。

b. 妇女在杀人时怀孕，关押的前一天孩子流掉，从关押到执行期间没有再怀过孕：能适用死刑，因为关押到执行期间内没有怀过孕。

c. 法条有此规定，是因为对于一个人来讲死并不可怕，天天等死才最可怕，如果法律规定一旦孩子出生就能判死刑，这很可怕，如孩子还有三个月出生，可能天天算着自己要死的日子，且孩子出生后就没有妈妈了，不人道。若法律规定妇女流产就能判死刑，里面的人不知道明天和意外哪个先到，很可怕。

d. 真实案例：一位女子已经判处死刑，在押赴刑场的过程中，突然和工作人员说自己怀孕了，不能给自己执行死刑，经过调查，该妇女确实怀孕了（不管怎么怀上），哪怕法院已经判完了，最后也进行了改判，改判为无期徒刑。

③审判时已满 75 周岁的老人，不适用死刑，但有例外，以特别残忍手段致人死亡的除外。

a. 比如一位 76 周岁的老大爷，大卸八块把人杀死，能适用死刑，因为老人有例外情形。“特别残忍手段致人死亡”，如大卸八块、烹煮、扒皮。

b. 以特别残忍手段致人死亡的情形只适用于老人，犯罪时不满 18 周岁和审判时怀孕的妇女这两类人没有例外情形，无论做了多么伤天害理的事通通不适用死刑，只有老人有例外情形。

④“不适用死刑”的含义：不适用死刑指既不适用死刑立即执行，也不适用死刑缓期执行，最多只能判无期徒刑。

2. 死刑适用程序的限制：因为死刑是最严厉的刑罚，判完之后需要有一个核

准的过程。

（1）如果判的是死刑立即执行，必须报请到最高人民法院（全国仅有北京一家）核准。

（2）如果判的是死刑缓期执行，死缓会缓 2 年，相对来讲没有那么急，上报时可以降一级，即可以报请到省高院核准。

3. 执行制度的限制——死缓：缓刑 2 年，在 2 年期间要在监狱里待着，在监狱的 2 年期间内，表现不同，结果不同。

（1）如果 2 年内没有故意犯罪，2 年时间一到就不用死了，变为无期徒刑。

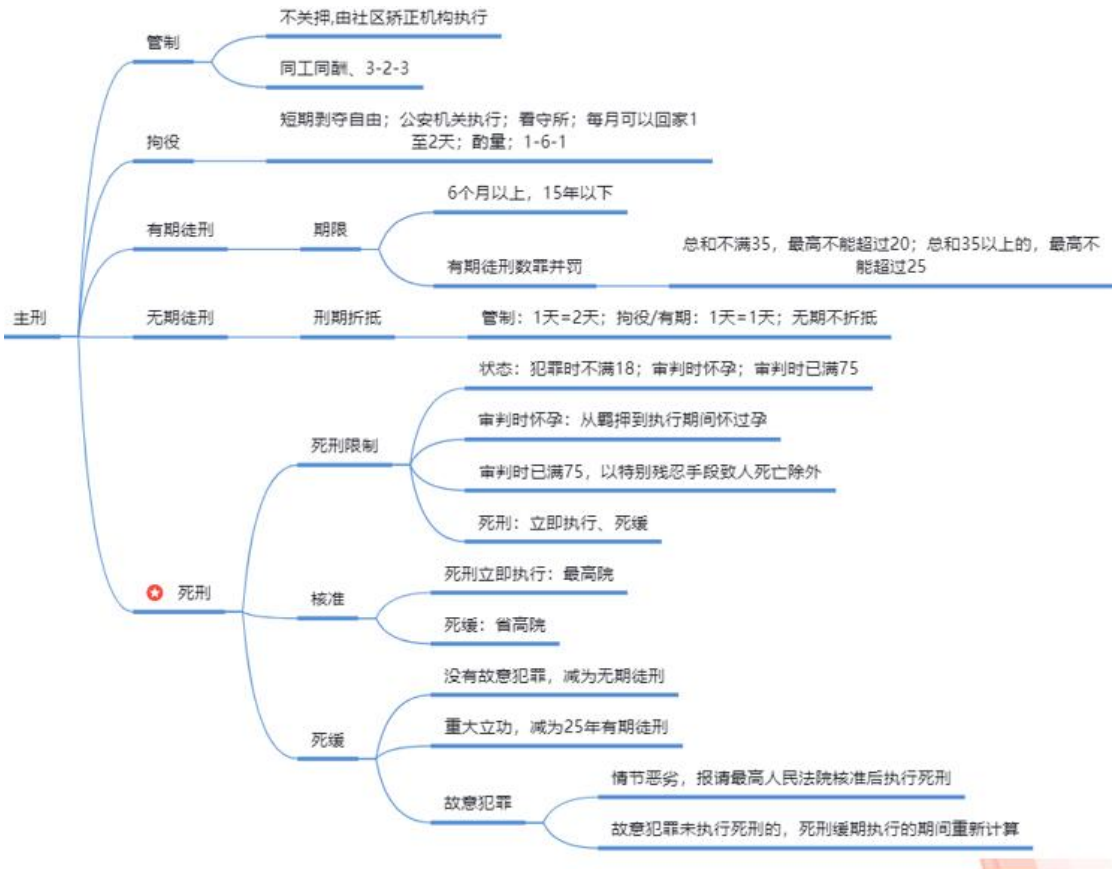
（2）如果 2 年内，不仅没有故意犯罪，而且还有重大立功表现（如检举重大贪污案件），变为 25 年有期徒刑。

（3）如果 2 年内有故意犯罪，也不会直接就死，要分情况，看故意犯罪的情节：

①如果情节不恶劣（如小偷小摸），此时再给一次机会，死缓是 2 年，这 2 年时间重新计算，看下一个 2 年表现如何。

②如果情节特别恶劣（如越狱，把狱警打死，和狱友发生冲突，把楼烧了、把人杀死了），说明这个人不想悔改了，此时报请到最高人民法院核准后执行死刑立即执行。

（4）从死缓的结果来看，如果一个人判了死缓，意味着在里面只要他自己不作妖就很难死掉，这也就解释了人们在生活中可能有的一些疑问，比如某人被判处死缓，但是被害人的家属往往不同意，要继续上诉，因为犯罪人很难死掉。



【注意】

1. 管制是短期剥夺犯罪分子的人身自由（错误），原因：管制不关押。

2. 拘役期间参加劳动叫做同工同酬（错误），原因：酌量发给报酬。

3. 拘役的刑期是 3-2-3（错误），原因：拘役在里面，是 1 打头（1-6-1）；管制在外面，是 3 打头（3-2-3）。

4. 我国有期徒刑最多能判 25 年。

5. 犯一个罪判处有期徒刑最高是 15 年。20 年是数罪并罚，X＜35 年；X≥35 年，最高 25 年。

6. 关于折抵刑期，管制 1：2 折抵，有期、拘役 1：1 折抵，无期徒刑不折抵（正确）。

7. 犯罪时不满 18 周岁、审判时怀孕的妇女、审判时已满 75 周岁的老人，一律不适用死刑（错误），原因：老人有例外。

8. 三类人不适用死刑指的是不适用死刑立即执行，但是可以适用死刑缓期执行（错误），原因：既不适用死立执，也不适用死缓，最多是无期徒刑。

9. 死刑立即执行也可以报请到省高院核准（错误），原因：必须报请到最高

院核准，死缓可以报请到省高院核准。

二、附加刑

1. 罚金

罚金是人民法院判处犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。

由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

【解析】附加刑：一般是附加适用，也可以单独适用。可以判主刑+附加刑，如判处 5 年有期徒刑+罚金 5 千元；也可以单独判处附加刑，如单独判处罚金 5 千元。

1. 主刑可以独立适用，并且只能独立适用，对一个行为只能适用一个主刑，不能适用多个主刑，如张三犯故意杀人罪，只能判一个主刑，如只能判有期或无期或死刑；犯多个罪，每个罪可以判一个主刑，涉及数罪并罚，如张三犯故意杀人罪和强奸罪，每个罪判一个主刑。

2. 张三故意杀人，判主刑+附加刑，如判 5 年有期、并处罚金 5 千元，即主刑是被附加刑附加的。判断：

（1）主刑可以被附加适用（正确）。

（2）主刑也能附加适用（错误），原因：主刑只能被附加适用，不能把一个主刑附加到另一个主刑上。

3. 一个罪可以判处多个附加刑：如张三故意杀人，附加罚金、剥夺政治权利。附加刑之间是并列的关系，没有高低之分，都是同样的地位。判断：一个附加刑也能附加到另一个附加刑上适用（错误），原因：大家都是附加刑，没有高低之分，是并列的。

4. 罚金：即交钱。罚金≠罚款。罚款是行政处罚中的内容，罚金是刑罚中的附加刑。记忆方式：罚金的“金”对应金子，更值钱。

5. 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除：罚金可以分期付款，如一个人确实有困难，对比减少、免除，分期更有利于国家。

2. 剥夺政治权利

剥夺政治权利，是指剥夺犯罪人参加国家管理和政治活动权利的刑罚方法。

（1）剥夺政治权利是剥夺犯罪分子下列 4 项权利：

①选举权和被选举权。

②言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利。

③担任国家机关职务的权利。

④担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。

（2）剥夺政治权利的适用

对于危害国家安全的犯罪分子，应当附加剥夺政治权利。

对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。

对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。

国安死无是应当，一串重罪是可以

【解析】剥夺政治权利：

1. 剥夺政治权利是剥夺犯罪分子下列 4 项权利：

（1）选举权和被选举权。

（2）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利（6 大自由）：如果一个人被剥夺政治权利，有写书、创作的自由，只不过不能出版。如甲被剥夺政治权利后可以写小说，但是不能出版。

（3）担任国家机关职务的权利：任何国家机关的职务都不能担任，比如不可以去国家机关中当一个普通的小科员。

（4）担任国有公司、（国有）企业、事业单位和人民团体领导职务的权利：理论上只剥夺领导职务，如果甲被剥夺政治权利，理论上可以到事业单位中担任普通的小职员，但实践中不行（涉及政审）。注意：不限制私企。

2. 剥夺政治权利的适用（两个应当，一个可以）：适用指什么时候应当（必须）剥夺，什么时候可以（有选择）剥夺。

（1）对于危害国家安全的犯罪分子，应当附加剥夺政治权利（必须/一定要剥夺）。

（2）对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序

的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。

（3）对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身（必须/一定剥夺）。

（4）口诀：国安死无是应当，一串重罪是可以。国安（危害国家安全的）死无（判处死刑、无期徒刑的）是应当（必须/一定要剥夺政治权利，且死刑、无期是剥夺终身），一串重罪是可以（对于一串重罪，是可以剥夺，也可以不剥夺）。

（5）考试中主要考查对应关系。判断：张三危害国家安全，可以剥夺政治权利（错误），原因：国安死无是应当，一串重罪是可以。

3. 没收财产

没收财产是将犯罪分子个人合法所有的财产的一部分或全部强制无偿地收归国有的刑罚方法。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。

【解析】没收财产：

1. 没收财产≠没收非法财物。

2. 没收财产指没收犯罪分子个人的合法财产（不没收家属的），没有古代的抄家制度。没收个人的合法财产，在刑法中，非法财产叫做理应收缴，无须没收。考试中，如果看到非法的东西，直接画“×”（不是刑法的内容）。

4. 驱逐出境驱逐出境，是强迫犯罪的外国人离开中国国（边）境的刑罚方法。

【解析】驱逐出境针对的仅仅是外国人，本国公民是不能够驱逐出境的，因为本国公民的家就在这里。

【注意】

1.附加刑既可以附加适用，也可以单独适用，如判主刑+附加刑，也可以单独判附加刑。

2.罚金：和罚款不同。

3.剥夺政治权利：剥夺 4 项权利。口诀：国安死无是应当，一串重罪是可以。

4.没收财产≠没收非法财物。没收犯罪分子个人合法财产。

5.驱逐出境针对的仅仅是外国人，本国公民是不能够驱逐出境的。

试题演练

1.（2023 四川省属·单选）下列关于刑罚种类的说法，正确的是（　）。

A.对于犯罪的外国人驱逐出境只能附加适用

B.对判处管制的犯罪分子，依法实行社区矫正

C.拘役的期限，为 1 个月以上 1 年以下，参加劳动的，可以酌量发给报酬

D.死刑缓期执行除由最高人民法院判决的以外，都应当报请最高人民法院核准

【解析】1.A 项：既能附加适用，也能单独适用，排除。C 项：拘役期限是“1-6-1”，数罪并罚最多 1 年，排除。D 项：死缓可以降一下，省高院即可，排除。【选 B】

2.（2022 四川宜宾·多选）属于我国刑法中的主刑的是（　）。

A.有期徒刑　　B.管制

C.罚金　　D.拘役

【解析】2.C 项：属于附加刑，排除。【选 ABD】

3.（2022 四川省属·单选）根据刑法规定，下列关于罚金的说法正确的是（　）

A.罚金不能分期缴纳

B.罚金不能单独适用

C.由于不可抗拒的灾祸，罚金可以依法减免

D.罚金数额应根据犯罪分子缴纳罚金的能力来确定

【解析】3.A 项：可以分期，排除。B 项：可以单独适用，排除。D 项：若法律这么规定，可能被钻漏洞，穷人就可以随意干坏事，因为没钱就无法处罚，应该根据犯罪情节确定数额，不是缴纳罚金的能力，排除。【选 C】

4.（2018 四川德阳·单选）关于管制，下列说法正确的是（　）。

A.管制的期限为 1 个月以上 6 个月以下

B.对判处管制的犯罪分子不予关押，依法实行社区矫正

C.判处管制的犯罪分子参加劳动的，可以酌情发给报酬

D.被判处管制的犯罪分子每月可以回家一至两天

【解析】4.A 项：管制在外面，3-2-3，排除。C 项：参加劳动是在外面干活，同工同酬，拘役在里面，是酌情、酌量发放，排除。D 项：管制天天在家，拘役是 1-2 天，排除。【选 B】

5.（2018 四川德阳·单选）关于附加刑的适用，下列说法正确的是（　）。

A.附加刑是补充主刑适用的刑罚方法，不能独立适用

B.罚金只能由法院依照刑法的规定对构成犯罪的单位适用，不对犯罪的自然人适用

C.没收全部财产时，应当将犯罪分子个人及其家属的所有财产收归国有

D.对于犯罪的外国人，可以独立适用驱逐出境

【解析】5.A 项：可以独立适用，排除。B 项：都能适用，排除。C 项：不存在连坐、抄家制度，只没收个人的，排除。D 项：既可以独立适用，也可以附加适用，当选。【选 D】

6.（2024 四川省属·判断）颠覆国家政权罪、分裂国家罪、间谍罪等危害国家安全罪，在追究刑事责任时应当附加剥夺政治权利。（　）

【解析】6.口诀：国安死无是应当，一串重罪是可以。【选 √】

7.（2023 四川省属· 判断）在我国刑法中，主刑只能独立适用，不能附加

适用。（　）

【解析】7.主刑只能独立适用，对一个犯罪只能独立适用一个主刑，不能适用多个主刑，如张三因为故意杀人罪判刑，只能判一个主刑，是独立的；若对一个行为判主刑+附加刑，对附加刑而言是附加到主刑上，对于主刑而言是被附加适用，如主刑被附加刑附加，不能表述“主刑也能附加适用”。【选√】

8.（2022 四川成都 •判断）被判处剥夺政治权利的罪犯无法享有著作权。（　）

【解析】8.著作权如创作，是可以的，只是不能出版。【选×】

9.（2021 四川省属 • 判断）管制的刑期，从判决执行之日起算，判决执行以前先羁押的，1 日折抵刑期 1 日。（　）

【解析】9.管制是 1：2，拘役、有期是 1：1，无期不折抵。【选×】

10.（2025 四川省属 • 单选）管制是主刑种类之一，下列关于管制的说法，错误的是（　）。

A.管制的期限，为三个月以上二年以下

B.对判处管制的犯罪分子，依法实行社区矫正

C.判处管制，可以禁止犯罪分子在执行期间接触特定的人

D.违反管制期间禁止令的，应当撤销管制，数额并罚

【解析】10.选非题。A 项：管制期限是 3-2-3，排除。C 项：禁止令，排除。D 项：按照《治安管理处罚法》的规定进行处罚，当选。【选 D】

第四节　刑罚的具体运用

一、累犯

累犯，是指因犯罪而受过一定的刑罚处罚，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在法定期限内又犯一定之罪的罪犯。

对累犯应当从重处罚。

累犯包括一般累犯和特殊累犯。

【解析】刑罚的具体运用：

1. 累犯：累教不改，至少犯了 2 次罪。因犯罪而受过一定的刑罚处罚，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在法定期限内又犯一定之罪的罪犯。

（1）刑罚执行完毕：前罪已经结束，该蹲的已经蹲完。

（2）赦免：在我国指特赦，如全国人常决定特赦一些人，国家主席颁布特赦令。

2. 对累犯应当从重处罚：累教不改。

3. 累犯包括一般累犯和特殊累犯（特别累犯）。

（一）一般累犯（2 个故意+2 个有期↑+五年之内）

一般累犯，是指被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在 5 年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的犯罪分子。

一般累犯的构成要件包括：

（1）前后两罪都是故意犯罪；

（2）前后两罪都应当是被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪；

（3）后罪在前罪的刑罚执行完毕或赦免以后 5 年之内；

（4）不满 18 周岁的人犯罪的，不成立累犯。

【解析】

1. 一般累犯：要同时满足 3 个条件，即 2 个故意+2 个有期以上+五年之内。

（1）2 个故意：前后两罪都是故意犯罪（过失犯罪不成立累犯，题目问是否构成累犯时看到过失犯罪直接画叉）。交通肇事罪：属于典型的过失性犯罪，不成立累犯。

（2）2 个有期以上：前后两罪都应当是有期徒刑以上（包括有期徒刑）刑罚的犯罪，如有期徒刑、无期徒刑，甚至死刑。

（3）五年之内：后罪在前罪的刑罚执行完毕或赦免以后 5 年之内（包括 5 年）再犯的。

（4）如张三因为盗窃（前罪）被判有期徒刑 3 年，出狱后第 4 年因抢劫罪被判 10 年有期徒刑，此时同时满足 3 个条件，成立一般累犯。一个条件不满足则不行，若前罪盗窃被判处拘役，则不成立一般累犯。

2. 一般累犯和特殊累犯都要年满 18 周岁，即不满 18 周岁的人犯罪的不成立

累犯。

（1）如某人前后两罪都是在 18 周岁之前所犯，不成立累犯；前罪在 18 周岁之前，后罪在 18 周岁之后犯的，不成立累犯。要想成立累犯，必须前后两个罪都要满 18 周岁。

（2）注意：不成立累犯指既不成立一般累犯，也不成立特殊累犯/特别累犯。题目中若告诉年龄，则看是否满 18 周岁。如果没有说明年龄，则默认年满 18 周岁。

（二）特别累犯

特别累犯，是指危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免后，在任何时候再犯上述任一类罪的情形。

【解析】

1. 特别累犯/特殊累犯：只需满足罪名即可，包括犯危害国家安全罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪，简称为“国恐黑”。前罪三种罪之一+后罪三种罪之一，满足罪名即可成立，不管判处的刑罚、中间间隔的年数。

2. 例子：

（1）张三前罪因危害国家安全罪被判拘役，出狱后的第 10 年因为恐怖活动犯罪被判处管制（前后罪都是国恐黑之一，不管刑罚、间隔多少年），此时成立特别累犯。

（2）张三前罪因间谍罪（典型的危害国家安全类犯罪）被判处有期徒刑，出狱后的第 6 年因抢劫罪被判处无期徒刑，此时不成立特别累犯，前罪属于“国恐黑”之一，后罪抢劫不属于三种罪之一。也不成立一般累犯，中间间隔 6 年无法构成，若前后两罪间隔是 5 年或者 4 年则可以。

3. 考查方式：

（1）给出案例，问这个人的行为能否构成累犯，用一般累犯的三个条件和特别累犯的一个条件来判断。

（2）考查累犯的十二字真言：不得缓刑，不得假释，可以减刑。

二、自首与立功

（一）自首

自首，是指犯罪分子犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的行为，或者被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的行为。

对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

犯 A+自动+供述 A　一般自首

犯 A+被抓+供述本人 B　特殊自首

犯 A+被抓+供述 A　坦白

【解析】

1. 自首：

（1）一般自首：犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的行为（“或者”前面的部分）。

①如甲去盗窃，盗窃完后主动到公安机关供述自己盗窃的罪行，成立一般自首。

②自动投案：只要主观上不反对、不反抗，想要交代事实，原则上认定为自动投案。

a. 如甲没时间投案，通过写信、打电话、发邮件进行投案，成立自动投案。

b. 被父母、亲友规劝投案的，成立自动投案。

c. 去投案的路上被警察抓住的，成立自动投案。

d. 如果是被捆绑去投案的，说明是反对、反抗的，不成立自动投案。

（2）特别自首/特殊自首：被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的行为。如甲去盗窃，被警察抓了，他告诉警察自己不仅偷东西，还杀了人，如何杀人、凶器藏在哪都告诉了警察，对于如实供述公安机关还没有掌握的本人的杀人行为，即特别自首。

（3）量刑：对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

2. 坦白：犯事后被抓归案，如实供述自己被指控的罪行。

（1）比如甲去盗窃，被抓后如实供述公安机关指控自己盗窃的行为。

（2）量刑：可以从轻（普通情形）或减轻处罚（避免特别严重后果），但不能免除处罚。

3.总结：

（1）犯 A 罪+自动+供述 A，构成一般自首。如甲去盗窃，自动归案，如实供述本人的盗窃行为，属于一般自首。

（2）犯 A+被抓+供述本人 B，构成特殊自首。如甲去盗窃，被抓归案，如实供述司法机关没有掌握的本人杀人行为，构成特殊自首。

（3）犯 A+被抓+供述 A，即坦白。如甲去盗窃，被抓归案，如实供述本人的盗窃行为，即坦白。

（4）自首、坦白、立功的量刑都是“可以”。

（二）立功

立功，是指犯罪分子揭发他人的犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等的行为。

对于有立功表现的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

【解析】

1.立功：立功，是指犯罪分子揭发他人的犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等的行为。如甲因为盗窃被抓，告知警察张三杀人的行为（怎么杀、凶器和尸体藏在哪），警察根据甲提供的线索成功侦破案件，此时属于立功。注意：立功说的是别人的事情，自首、坦白说的是自己的事情。

2.量刑：对于有立功表现的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

3.区分：立功、坦白、自首都是“可以”。

（1）立功：普通立功可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的（再优惠一档），可以减轻或者免除处罚。

（2）坦白：可以从轻（普通坦白）或者减轻处罚（避免严重结果发生）。

（3）自首：一般的自首可以从轻或减轻处罚。犯罪情节较轻的，可以免除

处罚。

三、数罪并罚

判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过 3 年，拘役最高不能超过 1 年，有期徒刑总和刑期不满 35 年的，最高不能超过 20 年，总和刑期在 35 年以上的，最高不能超过 25 年。

数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。

数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

【解析】数罪并罚：

1. 管制最高不能超过 3 年，管制是 3-2-3；拘役最高不能超过 1 年，拘役是 1-6-1。

2. 有期徒刑总和刑期不满 35 年的（X＜35），最高不能超过 20 年，总和刑期在 35 年以上的（X≥35），最高不能超过 25 年。

3. 判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期：如甲犯了两个罪，分别判处 3 年有期和 10 年有期，13 年是总和刑期，3 年和 10 年比，10 年是高的，最终人民法院会在 10-13 的区间内酌情定最终刑期。

4. 例子：

（1）甲犯了两个罪，分别判处 3 年有期和 5 年有期，总和是 8 年，数刑中 5 年高，即 5-8 年。

（2）甲犯了三个罪，分别判处 9 年有期、10 年有期、11 年有期，总和是 30 年，数刑中 11 年是高的，不能是 11-30 年，涉及封顶，X＜35 年，最高 20 年，人民法院最终会在 11-20 年定最终刑期。

5. 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑（即执行时间长的，相当于人道主义，进行了“折扣”）。数罪中有判处有期徒刑和管制（一个关押、一个不关押），或者拘役和管制的（一个关押、一个不关押），有期徒刑、拘役执行完

毕后（先执行关押的），管制仍须执行。如甲被判处有期/拘役，和管制数罪并罚，先执行关押的，再执行不关押的管制。

6.数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行：如甲 A 罪判处罚金 5 千元，B 罪也判处罚金 5 千元，合并为 1 万元；甲 A 罪判处罚金 5 千元，B 罪剥夺政治权利，分别执行即可。

四、缓刑（有条件的不执行原判刑罚）

（一）对象：被判处拘役、3 年以下有期徒刑的犯罪人。

（二）条件：1.犯罪情节较轻；2.确有悔改表现；3.无再犯可能性；4.宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

（三）缓刑适用的特殊规定

不满 18 周岁的人、怀孕的妇女和已满 75 周岁的人，应当宣告缓刑。

对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。

（四）被宣告缓刑的犯罪人，应当遵守下列规定

1.遵守法律、行政法规，服从监督。

2.按照考察机关的规定报告自己的活动情况。

3.遵守考察机关关于会客的规定。

4.离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。

【解析】缓刑：有条件的不执行原判刑罚。

1.真实案例：一个农民工的父亲生重病，没有钱治病，父亲很痛苦，求孩子给自己喂点药，让自己死亡。孩子不忍心，但是没办法看着父亲痛苦，只能给父亲喂药，父亲去世，这种行为在学术上称为安乐死。但是我国不承认安乐死，定为故意杀人罪。最终法官定的是故意杀人罪，三年有期徒刑缓期四年执行。缓期四年执行即缓刑，判完之后先不进监狱，回家待四年，四年当中对他进行考量，如果表现比较好，则不需要蹲监狱，正式自由。

2.注意：死缓和缓刑都叫“缓”，但是二者无关。死缓在监狱待着，缓刑在家里待着。

3.缓刑是指对被判处拘役、3 年以下有期徒刑的犯罪人（缓刑对象是轻罪）。注意：缓刑的对象没有管制，因为管制本来就在外面，没必要缓刑。条件：

（1）犯罪情节较轻。

（2）确有悔改表现。

（3）无再犯可能性。

（4）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

4. 当一个人同时满足缓刑条件（犯罪情节较轻，具有悔改表现），不满 18 周岁的人、怀孕的妇女和已满 75 周岁的人，符合条件应当宣告缓刑。

5. 对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。累犯，不得缓刑，不得假释，可以减刑；犯罪集团的首要分子如黑帮的老大，不得缓刑。

6. 注意：

（1）判断：法官审理不满 18 周岁的人犯罪，一律都要宣告缓刑（错误），原因：假如犯的是重罪，或者没有悔改表现，则不能宣告缓刑。法院在审理不满 18 周岁的未成年人犯罪时，符合条件（符合对象条件、情节条件）应当宣告缓刑。

（2）一个人同时符合对象条件和情节条件，是已满 75 周岁的老人，同时是犯罪集团的首要分子，此时不得缓刑。意味着只要这个人是累犯或是犯罪集团的首要分子，没有任何可能性，就是不得缓刑。

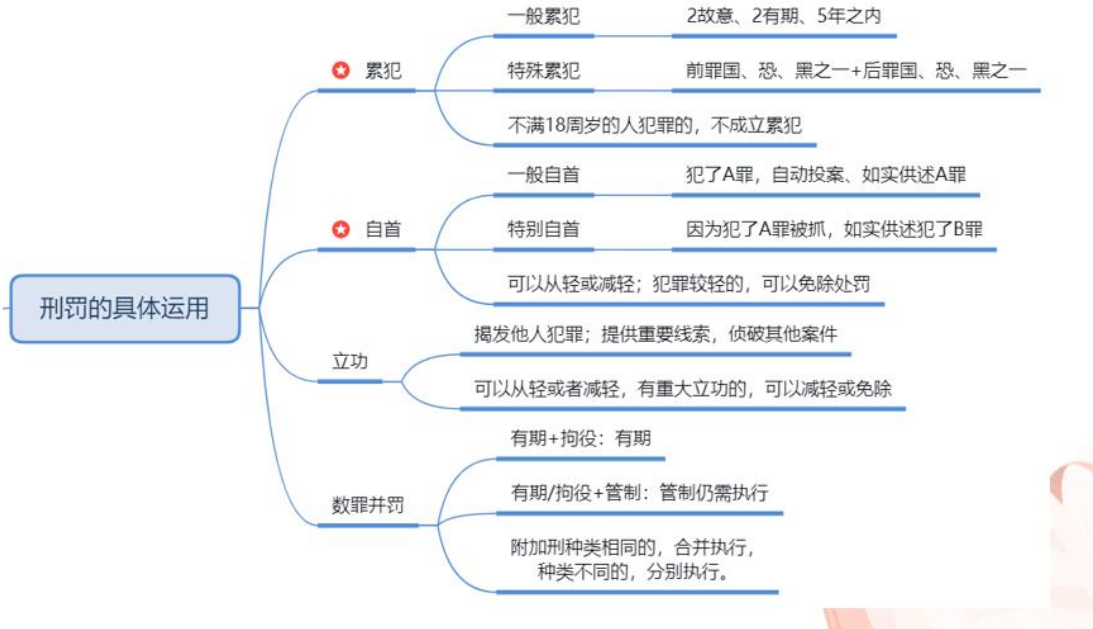
7. 被宣告缓刑的犯罪人，应当遵守下列规定：

（1）遵守法律、行政法规，服从监督。

（2）按照考察机关的规定报告自己的活动情况。

（3）遵守考察机关关于会客的规定。

（4）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。



【注意】

1. 一般累犯要求 2 故意、2 有期以上、3 年之内（错误），原因：5 年之内。

2. 特殊累犯要求前罪是国恐黑之一，后罪任意罪名都可以（错误），原因：后罪也要求是国恐黑之一。

3. 对于累犯，不得缓刑，不得假释，可以减刑（正确）。

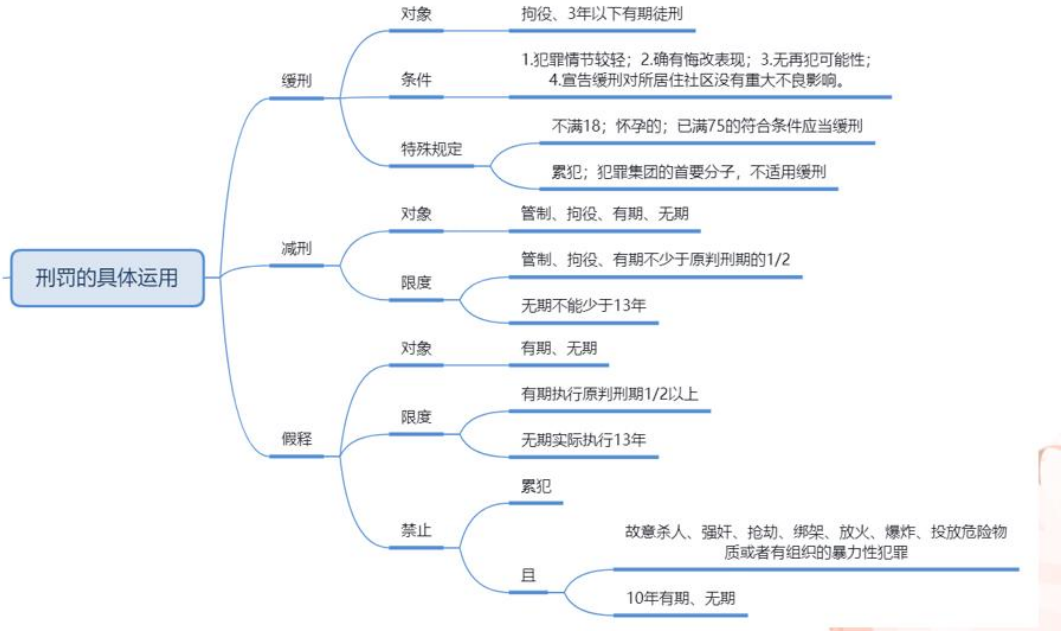
4. 犯 A 罪，主动归案，如实供述本人的 A 罪：一般自首。

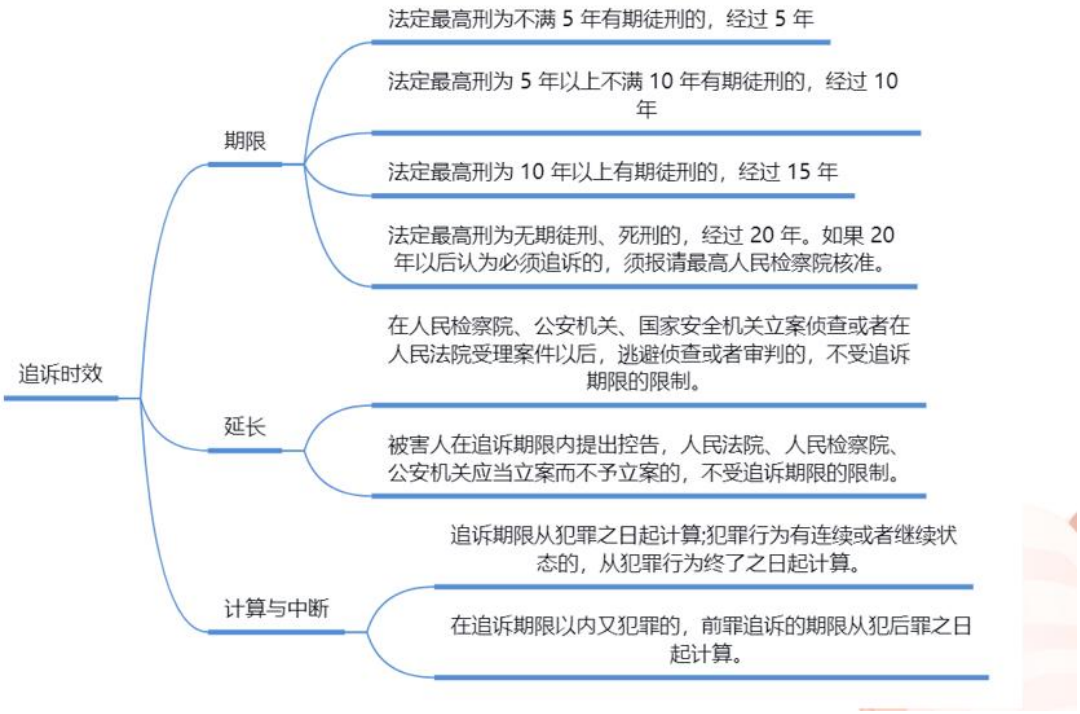
5. 犯 A 罪，被抓归案，如实供述司法机关未掌握的 B 罪：特殊自首。

6. 犯 A 罪，被抓归案，如实供述 A 罪：坦白。

7. 附加刑，种类相同的合并执行；种类不同的分别执行。

8. 管制和有期徒刑数罪并罚，先执行有期，管制仍需执行。





试题演练

1.（2023 四川成都·单选）2012 年 3 月，李四因入室盗窃被判有期徒刑 2 年。2020 年 10 月，李四又犯抢劫罪。关于李四，下列表述正确的是（　）。

A. 只有抢劫的财物数额较大才构成抢劫罪

B. 李四在被抓后如实供述自己的抢劫行为，构成自首

C.李四构成累犯，应当从重处罚

D.李四若在抢劫后主动投案，如实交代案情，可从轻或减轻处罚

【解析】1.A 项：抢劫罪一般不要求数额，排除。B 项：属于坦白，排除。C 项：2014-2020 年，已经超过 5 年，不构成累犯，排除。D 项：犯 A 罪，主动归案，如实供述本人的 A 罪，一般自首，可以从轻或减轻处罚，当选。【选 D】

2.（2022 四川省属·单选）下列不属于构成一般累犯条件的是（　）。

A.前罪与后罪都是故意犯罪

B.前罪与后罪都应被判处有期徒刑以上刑罚

C.后罪发生在前罪的刑罚执行完毕或赦免以后 5 年之内

D.犯罪主体前后两次犯罪都需已满 16 周岁

【解析】2.选非题。D 项：要年满 18 周岁，当选。【选 D】

4.（2021 四川内江·单选）以下构成累犯的是（　）。

A.甲因故意伤害被判一年有期徒刑，2000 年 1 月 1 日刑满释放，2000 年 9 月 9 日又因为失火罪被判两年有期徒刑

B.乙因故意伤害被判一年有期徒刑，2000 年 1 月 1 日刑满释放，2000 年 9 月 9 日又因为危险驾驶被判五个月拘役

C.丙因参加黑社会性质组织罪被判刑，2000 年 1 月 1 日刑满释放，2009 年 9 月 9 日又因为过失致人死亡被判三年有期徒刑

D.丁因故意伤害被判一年有期徒刑，2000 年 1 月 1 日刑满释放，2003 年 9 月 9 日又因为抢劫罪被判五年有期徒刑

【解析】4.A 项：失火罪不能构成累犯，排除。B 项：拘役不能构成累犯，排除。C 项：过失不能构成累犯，排除。【选 D】

5.（2018 四川绵阳·多选）下列关于自首的表述，正确的是（　）。

A.对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，其中，犯罪较轻的，可以免除处罚

B.被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法

机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论

C.对于自首的犯罪分子，应当从轻或者减轻处罚，其中，犯罪较轻的，应当免除处罚

D.被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关未掌握的本人其他罪行的，不以自首论

【解析】5.C 项："应当"应该是"可以"，排除。D 项：可以以自首论，排除。【选 AB】

6.（2018 四川绵阳·单选）关于缓刑的表述，下列正确的是（　）。

A.对于被判处拘役、3 年以下有期徒刑的犯罪分子应判处缓刑

B.被宣告缓刑的犯罪分子，可以不遵守考察机关关于会客的规定

C.被宣告缓刑的犯罪分子，离开所居住的市、县或者迁居，不必报经考察机关批准

D.对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑

【解析】6.A 项：可以判处缓刑，排除。【选 D】

7.（单选）甲、乙、丙三人共同杀害王某，甲一直潜逃，乙、丙被抓，乙被抓之后，揭发了甲除了杀害王某还曾在 3 年前有过强奸行为。后甲被抓，公安机关审讯中发现甲 3 年前确实有过强奸罪。乙的行为属于（　）。

A.自首　　B.立功

C.坦白　　D.配合调查

【解析】7.【选 B】

遇见不一样的自己

Be your better self